

1009981-54.2022.8.26.0361

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: Fabricio Henrique Canelas

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Cível

Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza 159, Mogi das Cruzes - SP - cep 08780-912

1009981-54.2022.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1009981-54.2022.8.26.0361

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Maria Aparecida de Moraes Manna

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.a.

Prioridade Idoso

CONCLUSÃO

Em 25 de novembro de 2022^o faço conclusão destes autos ao MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Dr(a). Fabricio Henrique Canelas

Vistos.

Maria Aparecida de Moraes Manna move ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização em face de Banco Mercantil do Brasil S.a., alegando, em síntese, que possui conta bancária junto ao requerido e, em 18/04/2022, recebeu um SMS em nome dele solicitando confirmação sobre empréstimo supostamente realizado, constando a opção "sim" para confirmar e um número de telefone "0800" para contestar. Ao ligar para o número de telefone informado, a atendente orientou que a autora baixasse o aplicativo "Team Viewer" para realizar verificações. Então a atendente solicitou que a autora redigisse carta de próprio punho declarando não reconhecer o empréstimo, bem como deixasse seu celular em um local alto para evitar problemas de rede. A atendente também orientou a não utilizar o aplicativo do banco pelo prazo de 24h. No entanto, a requerente percebeu que todas as suas mensagens de SMS e histórico da ligação via "0800" haviam sido excluídos, assim como desinstalado o aplicativo do banco. Ao acessar seu extrato bancário, a requerente identificou 4 operações financeiras que não foram por ela realizadas, quais sejam: contrato 805075132 (renovação de empréstimo consignado de R\$25.000,00), contrato 805075134 (contratação de empréstimo pessoal de R\$3.891,00)

e contrato nº 910001325421 (contratação de empréstimo para antecipação do 13º salário, no valor de R\$553,00). Embora tenha havido a renovação de empréstimo no valor de R\$25.000,00, foi liberado apenas o valor de R\$4.286,53 pois o restante serviu para quitar empréstimo anterior. Logo em seguida à realização dos empréstimos, o fraudador realizou pix no valor de R\$9.355,00 em favor de Weliton Rodrigues dos Santos, ensejando a cobrança de R\$625,47 a título de cheque especial. Ao pedir o cancelamento das operações bancárias pela via administrativa, o réu informou que não seria possível porque a autora teria cedido informação sobre senhas e teria permitido acesso remoto de terceiro em seu celular. A requerente justifica, porém, que realizou os procedimentos orientados por suposto funcionário do banco a fim de cancelar empréstimo não solicitado. Assim, pede a declaração de inexigibilidade dos empréstimos e do saque de cheque especial acima mencionados. Pleiteia a inversão do ônus da prova com base no CDC e aduz ter ocorrido falha no sistema de segurança do réu, que não identificou a movimentação fora do padrão habitual da autora. Invoca a Súmula 479 do STJ. Pede a concessão de justiça gratuita, prioridade de tramitação por idade e tutela de urgência para que o réu se abstenha de negativar os débitos questionados, bem como de cobrar as parcelas dos empréstimos fraudulentos. Juntou documentos.

Deferida a justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação do feito por idade, houve emenda à inicial para juntada de extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, bem como para esclarecer que o valor apontado como cheque especial resultou da realização de pix pelo fraudador em valor superior aos empréstimos contratados.

Deferida a tutela de urgência e recebida a inicial, foi o réu citado por meio de carta com aviso de recebimento.

Em contestação, o réu alegou ilegitimidade passiva, pois os fatos narrados na inicial evidenciam culpa exclusiva do consumidor, que forneceu senha ao fraudador e acesso remoto a seu celular, não se vislumbrando falha de segurança do serviço prestado pelo banco. No mérito, reitera tais alegações, acrescentando que a autora tinha ciência sobre o caráter sigiloso da senha e que ela mesma admite ter realizado declaração de próprio punho manifestando interesse na contratação do empréstimo. Afirma não ser possível a devolução em dobro dos valores descontados porque não há prova de má-fé do banco. Reputa incabível indenização por danos morais. Pugna pela improcedência e compensação de créditos.

O INSS informou não haver qualquer empréstimo ativo referente ao réu no benefício previdenciário 158.440.554-3 (fls. 113/116).

Na réplica, a autora insiste na legitimidade passiva do requerido, porque concedeu os empréstimos questionados, reitera que a declaração de próprio punho solicitada pelo fraudador era no sentido de não reconhecer o empréstimo, bem como que houve falha de segurança no serviço por ausência de confirmação sobre as operações destoantes do perfil do cliente. Reforça o pedido para que sejam declaradas inexigíveis as operações bancárias questionadas, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados, com base em tais contratações. Afirma não ter realizado pedido de devolução em dobro destes valores, nem de indenização por danos morais.

Intimadas as partes para especificação de provas, apenas a autora se manifestou, requerendo o depoimento pessoal "das partes".

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de julgamento antecipado da lide, pois os elementos dos autos já permitem a formação de convicção pelo julgador.

Evidente a legitimidade passiva do réu, pois consta como beneficiário dos créditos questionados.

Restou incontroversa a ocorrência de fraude no caso em tela, tendo o réu apenas alegado que a autora contribuiu de forma decisiva para sua realização, ao permitir acesso remoto do fraudador a seu celular, bem como fornecer senha de uso pessoal. A autora, por sua vez, não nega ter conhecimento sobre o sigilo da senha, mas alega ter sido ludibriada pelo fraudador, que enviou SMS em nome do banco solicitando confirmação de empréstimo e, posteriormente, requerendo procedimentos para o

respectivo cancelamento (frise-se que a autora afirmou ter redigido declaração questionando o suposto empréstimo realizado em seu nome, não para demonstrar interesse na contratação).

Em contexto semelhante, de fornecimento de dados pessoais sigilosos pelo consumidor a fraudadores, há julgados do STJ reconhecendo a existência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, com exclusão de responsabilidade do fornecedor (por exemplo: REsp n. 2.009.790, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/08/2022; REsp n. 2.010.841, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/08/2022).

Ocorre, porém, que a autora é idosa (fls. 17/18), sendo mais vulnerável à aplicação de golpes, sendo certo que algumas instituições financeiras costumam enviar mensagens aos consumidores informando sobre operações bancárias realizadas em seu nome, embora o réu afirme não praticar tal conduta.

O art. 6º, VIII do CDC, por sua vez, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil sua alegação ou quando houver hipossuficiência, sendo evidente o desconhecimento da autora sobre a forma de realização e cancelamento de empréstimos, além de ser, em tese, verossímil contato com instituição financeira por meio de número telefônico de prefixo "0800".

Em casos semelhantes, e ainda que o consumidor tenha contribuído com a ocorrência da fraude, o C. STJ tem jurisprudência diversa, interpretando os fatos à luz da hipervulnerabilidade do idoso, segundo regimento jurídico específico:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

9/8/2022, DJe de 18/8/2022.). No mesmo sentido: AREsp n. 2.197.605, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/09/2022.

"RECURSO ESPECIAL Nº 1979662 - SP (2022/0006409-8)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO E CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CASO CONCRETO. CONSUMIDOR IDOSO. PROTEÇÃO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de recurso especial interposto por TAIS TOSTES GRAZIANO em face de acórdão do TJSP que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL SA para reformar a sentença de procedência de ação declaratória de inexistência de débito oriundo de empréstimo bancário contratado mediante a prática do "golpe do motoboy", nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Negativa de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora, que foi vítima de golpe ao entregar seu cartão a terceiro desconhecido. Imprudência da titular do cartão ao confirmar dados a terceiro por telefone, inclusive com digitação de senha, realizando conduta diversa das normas de segurança que devem ser observadas pelos correntistas. Inexistência de nexo causal. Falha na prestação de serviços do banco não configurada. Débito exigível. Indevido o ressarcimento dos valores referentes às operações contestadas. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a recorrente apontou, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos: (i) arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, alegando que o golpe do motoboy é sofisticado, razão pela qual só a instituição financeira pode identificar a atuação de estelionatários, não sendo, por esse motivo, aplicável a excludente da responsabilidade pela inexistência de defeito ou pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (ii) arts. 186 e 927, parágrafo único, do CC, sustentando que há falha na prestação de serviços pela instituição financeira que permite a ação fraudulenta de terceiro, motivo pelo qual ela deve ser considerada responsável pelo dano.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 388/393 (e-STJ).

É o relatório.

Passo a decidir.

O presente recurso merece ser provido.

O cerne recursal cinge-se em aferir a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos valores contratados a título de empréstimo bancário em nome da parte recorrida, mediante fraude praticada por terceiros, no conhecido "golpe do motoboy".

A recorrida aponta, em síntese, a violação aos arts. 14, do Código de Defesa do Consumidor e 927, do Código Civil, ao argumento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A respeito da matéria, a Terceira Turma recentemente decidiu que, quando a entrega do numerário ou contratação ocorre em virtude do uso do cartão original e da senha pessoal do correntista, há participação do consumidor no nexo causal no resultado da fraude praticada por terceiro.

Ponderou, todavia, que, como também é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores, há participação de sua negligência no nexo causal do qual decorre o prejuízo.

Concluiu, assim, que, no caso conhecido como "golpe do motoboy", há "a concorrência de causas que permite e fomenta o evento danoso, a saber, a rápida lucratividade do golpe" (REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), o que poderia gerar o efeito previsto no art. 945 do CC.

Entretanto, tratando-se de consumidor idoso, como ocorre na hipótese, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável", devendo, assim, nessas circunstâncias, ser declarada "a inexigibilidade de todas as transações bancárias não reconhecidas pelo recorrente" (REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, no caso concreto, a orientação adotada pelo acórdão recorrido, de que "não há que se imputar ao banco a responsabilidade pelo dano material sofrido pela apelada, pois o réu em nada contribuiu para a ocorrência dele, sendo indevido o ressarcimento dos valores contestados" (e-STJ, fl. 312), não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, com substrato no art. 932, V, a, do CPC c.c. a Súmula 568/STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.

Advirto as partes que a oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas.

Intimem-se.

Brasília, 19 de setembro de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator"

(REsp n. 1.979.662, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 27/09/2022.)

Ademais, os documentos de fls. 55/56 demonstram a realização de operações típicas em casos de fraude, ou seja, diversas operações realizadas de forma seguida, inclusive de alto valor, seguida de transferência bancária, o que denota falha de segurança no serviço prestado pela financeira, pois, como visto nos precedentes acima, tem o dever de monitorar eventual ocorrência de ilícito por meio capaz de reconhecer, com eficiência e rapidez, operações suspeitas e divergentes do padrão do cliente.

Aplica-se no caso, portanto, a Súmula 479 do STJ e Tema 466 do mesmo tribunal, isto é, a responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno, inclusive pelo risco da atividade.

Assim, devem ser declaradas inexigíveis as operações bancárias questionadas e descritas na inicial, com a consequente devolução de valores descontados com base em tais operações, a serem apurados em fase de liquidação por arbitramento, mediante a juntada de extratos bancário e previdenciário.

Não houve pedido de indenização por danos morais, nem restituição em dobro dos valores descontados por conta dos empréstimos em questão.

Apesar do pedido constante na contestação, não se vislumbra qualquer crédito do réu a ser compensado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexigibilidade das operações questionadas na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência já deferida, bem como para condenar o réu a devolver, na forma simples, os valores descontados com base nas mencionadas operações, com correção monetária desde os descontos e juros moratórios desde a citação, uma vez não demonstrada a data da contestação administrativa (fls. 61) e existente relação contratual entre as partes (já que a autora afirma possuir conta bancária junto ao réu).

Ante a sucumbência, fica somente o réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R\$5.203,07 (item 4.1 da tabela de honorários da OAB), com fulcro no art. 85, § 8º-A do CPC.

P.I.C., arquivando-se oportunamente.

Mogi das Cruzes, 10 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA